

1502786-23.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... da prática do crime de posse de instrumentos para o tráfico (art. 34 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que o referido tipo penal deve ser absorvido pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), pois o crime de posse de instrumentos é, no caso, mero ato preparatório para o segundo, e, assim, o comportamento descrito pela norma consuntiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502786-23.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502786-23.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VINICIUS TERTU DA SILVA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

VINÍCIUS TERTU DA SILVA, LARISSA MATOS DOS SANTOS PIMENTEL e PRISCILA DE SOUZA MELLO, qualificados a fls. 10/11, 16/17 e 13/14, foram denunciados como incurso nos art. 33, "caput", e art. 34 c.c, todos da Lei n. 11.343/06 e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal, porque, no dia 18 de agosto de 2019, por volta de 15h20min, na Avenida Carlos Martiano Bitencourt, nº 462, no bairro Aviação, nesta Comarca, praticaram as seguintes condutas:

a) agindo em comparsaria entre si e com o adolescente M..M.B., tinham em depósito e guardavam drogas, consistentes em 270 porções de maconha, 01 tijolo pesando 995g de crack, 8.150 eppendorfs de cocaína e mais 3,185 kg da mesma substância a granel, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

b) possuíam e guardavam instrumentos destinados à fabricação, produção e transformação de drogas, consistentes em 02 balanças de precisão, 30 mil eppendorfs vazios e uma faca de cozinha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

c) corromperam o menor de 18 anos M.M.B. e com ele praticaram o crime de tráfico supracitado.

Laudo de exame químico toxicológico (fl. 373/376).

Os réus foram notificados a fls. 150, 159 e 210, ofertaram resposta à acusação a fls. 160/168, 183/186, 187 e 192/197 e a denúncia foi recebida a fls. 198/199.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 352).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fl. 380/389).

A Defesa do réu Vinícius pugnou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, absolvição com relação ao delito do art. 34 da Lei de Drogas, aplicação do redutor em grau máximo, detração, regime aberto, substituição por pena restritiva de direito e direito de recorrer em liberdade (fl. 392/427).

A Defesa das rés Larissa e Priscila requereu absolvição por insuficiência probatória e, sucessivamente, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, pena mínima, reconhecimento de causa de diminuição de pena, absolvição da prática do art. 244-B do Eca (fl. 434/440).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 03/06, auto de exibição e apreensão de fls. 08, do auto de constatação preliminar de fls. 09, laudo de exame químico toxicológico de fls. 373/376 e prova oral colhida em juízo.
A autoria é certa e recai sobre os acusados.

Em juízo, o policial Diego reconheceu os réus. Estavam em patrulhamento no local dos fatos e, ao passarem na frente da casa, Vinícius estava fumando maconha, fugiu e foi pego pulando o muro de trás da casa. Dentro do imóvel estavam as rés e um menor de idade, no quintal, com um quantidade menor de maconha e mais de dez quilos de cocaína, além de um tijolo de cor amarelada que deve ser crack, apenas este ainda não individualizado. Havia cocaína embalada e também a granel. Eles disseram que estavam desde as 02 horas e que receberiam R\$ 100,00 pelo serviço. As drogas pertenciam a um tal de Boy do Tude Bastos. Vinícius não residia no imóvel e na posse dele foi encontrado apenas um cigarro de maconha.

No mesmo sentido o depoimento do policial Marco Antonio.

A testemunha de defesa Ana Paula, disse que é amiga das rés e mora próximo a elas, mas não estava presente na hora dos fatos, pois encontrava-se na praia com a mãe da Priscila, aguardando a vinda delas. Nunca presenciou as rés fazendo uso de

entorpecentes, nem que participavam do tráfico de drogas.

Em juízo, o réu Vinícius negou a prática dos delitos. Disse que estava voltando da praia com um "baseado" e, ao ver os policiais, assustou-se e entrou na casa porque a porta estava meio aberta. Nunca havia entrado antes no local e não conhece as rés e nem o adolescente. Entrou na casa para fugir, mas foi preso no muro.

A ré Priscila, em juízo, negou os fatos. Já foi presa por tráfico, mas estava cumprindo as medidas em regime aberto. No dia era aniversário de sua irmã e estava indo à praia junto com Larissa. Era usuária de drogas e foram ao local para comprar entorpecentes de outra pessoa, que não era Vinícius. Enquanto aguardavam o troco, Vinicius apareceu correndo e as empurrou para dentro da casa, mas não estavam no local. Não conheciam Vinícius e nem o adolescente.

A ré Larissa, em juízo, também negou os fatos. Estava com Priscila e foram comprar um cigarro de maconha. Enquanto esperavam o troco, começou a confusão de gente correndo e foram parar dentro da casa, mas não tem ligação com os demais réus, apenas conhece Priscila há muitos anos. Vinícius estava na porta do local fumando e depois só o viu em outra viatura.

O adolescente M.M.B., quando ouvido em solo policial, afirmou: "(...) O declarante neste ato se acha acompanhado de seu avô paterno, o qual detem sua guarda judicial - Processo 1007630-95.2015.8.26.0477, o Senhor Carlos Humberto Barsanti. O

declarante estava na casa de seu genitor acompanhado de seus três colegas apenas de vista, sabendo apenas o nome de Priscila. Hoje, o declarante chegou na casa de seu pai por volta das 10:00 horas da manhã e já encontrou seus colegas (Priscila, Vinicius e Larissa), mas seu pai não estava na casa e lá permaneceu o esperando.

Que estava ajustado de receber juntamente com os demais colegas a quantia de cem reais cada um por dia para embalar as drogas para o comércio ilegal. Que as drogas que estavam na casa de seu pai é de um tal de Boy, o qual ligou algumas vezes em seu celular. O declarante informa que não sabe precisar a quantidade de drogas que estava embalando, sabe apenas que era bastante (cocaína e maconha). Não sabe os dados deste tal de Boy e onde possa ser encontrado. Não é viciado em drogas.

Estava estudando na Escola Padim. Que seu pai já esteve preso por receptação. Que já foi apreendido também por receptação. (...)". (grifei)

Como se vê, a versão apresentada pelo adolescente logo após a prisão em flagrante é bem diferentes dos relatos dos réus em juízo, pois aquele afirmou categoricamente que todos se conheciam e estavam no local para embalar drogas. No mais, o adolescente foi representado e condenado pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas sobre os mesmos fatos, o que reforça o entendimento de que todos estavam envolvidos.

Assim, em que pesem os argumentos dos combativos Defensores, é fato que os réus foram presos dentro do local e as versões apresentadas em juízo são inverossímeis. Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com que se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos encontram-se em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente os réus, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada destes em prejudicá-los gratuitamente com tão grave acusação.

Registre-se: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da

Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei)

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal dos réus, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas por todos e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a natureza e, especialmente, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, tudo a comprovar que estavam embalando drogas para fins de comercialização.

Por outro lado, no que tange à imputação da prática do crime de posse de instrumentos para o tráfico (art. 34 da Lei nº 11.343/06), verifica-se que o referido tipo penal deve ser absorvido pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), pois o crime de posse de instrumentos é, no caso, mero ato preparatório para o segundo, e, assim, o comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na concretização do perigo de lesão ao bem jurídico saúde pública, aplicando-se, então, o princípio de que major absorvet minorem, pois os fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de minus e plus, de conteúdo e continente, de parte a todo, de meio a fim, de fração a inteiro, razão, pela qual, o crime-meio deve ser absorvido pelo crime-fim. Assim, aplica-se ao caso o princípio da consunção, pois, duas normas, a consuntiva e consunta, estabelecem fases distintas de uma mesma conduta violadora do mesmo bem jurídico penalmente tutelado, apresentando, portanto, como já mencionado, relação de minus e plus, eis que "o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório.

Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma Lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. Deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, ou seja, relevante analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela." (STJ-5ª Turma, AgRg no AREsp nº 303213/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/10/2013, DJe 14/10/2013). (grifei)

No que tange à infração prevista no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, comprovado o envolvimento de adolescente, é o caso de adotar o entendimento do STJ em sua Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal -, sob pena de punir da mesma forma agentes que não envolvem e outros que contam com o auxílio de adolescentes em infrações penais. Resta evidente que nesta situação a gravidade do delito é maior, pois o adolescente costuma ser mais destemido e, quando pego, sempre procura sustentar a autoria do ato, ciente de que será apenado de forma mais branda com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Deve-se reconhecer o concurso material de delitos entre esta infração e o tráfico praticado, conforme prevê o art. 69 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

A) ABSOLVER os réus VINÍCIUS TERTU DA SILVA, LARISSA MATOS DOS SANTOS PIMENTEL e PRISCILA DE SOUZA MELLO, qualificados a fls. 10/11, 16/17 e 13/14, da prática do art. 34 da Lei 11.343/06;

B) CONDENAR os réus VINÍCIUS TERTU DA SILVA, LARISSA MATOS DOS SANTOS PIMENTEL e PRISCILA DE SOUZA MELLO, qualificados a fls. 10/11, 16/17 e 13/14, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Em razão disso, passo a dosar a pena separadamente de todos, em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da lei 11.343/06.

1. VINÍCIUS TERTU DA SILVA

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em

observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário (fl. 35). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Foi preso com enorme quantidade de entorpecentes variados, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. Assim, fixo a pena base do tráfico acima do mínimo legal:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal;

B) Art. 244-B da Lei 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, ausente agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 03), reduzo a pena do delito de tráfico para:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal;

B) Art. 244-B da Lei 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33, pois não pode ser visto como mero traficante ocasional a quem foi confiada tamanha quantidade e variedade de drogas. Nota-se, portanto, nítido envolvimento no meio delito, apto a afastar o redutor supramencionado.

Somo as penas aplicadas, ante o concurso material.

PENA DEFINITIVA: 07 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida no atinente à multa do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal, como pretendido pela defesa. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

O réu responde solto ao feito, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

2. LARISSA MATOS DOS SANTOS PIMENTEL

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré é primária (fl. 38/39). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Foi presa com enorme quantidade de entorpecentes variados, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. Assim, fixo a pena base do tráfico acima do mínimo legal em:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal;

B) Art. 244-B da Lei 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33, pois não pode ser visto como mera traficante ocasional a quem foi confiada tamanha quantidade e variedade de drogas. Nota-se, portanto, nítido envolvimento no meio delito, apto a afastar o redutor supramencionado.

Somo as penas aplicadas, ante o concurso material.

PENA DEFINITIVA: 08 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal.

Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida no atinente à multa do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal, como pretendido pela defesa. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

A ré responde solta ao feito, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

3. PRISCILA DE SOUZA MELLO

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré é reincidente, o que será levado em conta na segunda fase da dosimetria (fl. 43/45). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Foi presa com enorme quantidade de entorpecentes variados, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. Assim, fixo a pena base do tráfico acima do mínimo legal em:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal;

B) Art. 244-B da Lei 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, ausente atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fl. 43/45), aumento a pena de ambos os delitos para:

A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 933 dias-multa, no mínimo legal;

B) Art. 244-B da Lei 8.069/90: 01 ano e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33, ante a reincidência específica da acusada.

Nota-se, portanto, nítido envolvimento no meio delito, apto a afastar o redutor supramencionado.

Somo as penas aplicadas, ante o concurso material.

PENA DEFINITIVA: 10 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 933 dias-multa, no mínimo legal.

Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida no atinente à multa do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal, como pretendido pela defesa. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, bem como a reincidência e a quantidade de pena aplicada, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

A ré responde solta ao feito, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para contraprova.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando as condenações, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA